

1500322-20.2021.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o réu realizava o tráfico na residência, o que ensejou a ida dos castrenses até o local em que o acusado foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500322-20.2021.8.26.0580- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500322-20.2021.8.26.0580 - 2021/002412

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN RIBEIRO AVELINO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. LUAN RIBEIRO AVELINO, qualificado nos autos (fls. 12/13), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, supostamente, tinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 27 (vinte e sete) tabletes de maconha, com peso líquido total de 12,500 kg (doze quilos e quinhentos gramas), além de 1 (uma) porção de 'haxixe' (fls. 108/110).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 106).

O acusado foi notificado (fl. 140) e, após a apresentação da defesa prévia (fls. 128/129), a denúncia foi recebida (fls. 141/142).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, três testemunhas arroladas pela defesa e o réu interrogado (fls. 206/207).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 683/694) e do d. Defensor, preliminarmente, pela ausência de autorização para que os policiais adentrassem na residência e, no mérito, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4, da Lei nº 11.343/06, fixando-se regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fls.

703/714).

É o relatório.

2. Da alegação de ausência de autorização para que os policiais adentrassem na residência.

Os policiais foram uníssonos ao afirmarem categoricamente que o acusado Luan franqueou a entrada dos militares no imóvel. Aliás, o próprio acusado, em Juízo, quando do seu interrogatório, aduziu que um dos policiais afirmou que era para o acusado gravar um vídeo, dizendo que autorizava a entrada deles no imóvel.

Vale ressaltar que durante o depoimento dos policiais em Juízo, foram mostrados dois vídeos gravados, disponibilizados pelas testemunhas sobreditas, sendo que em um deles consta o acusado autorizando o ingresso dos policiais na residência, e no outro, o cão farejador encontrando a droga na estante (fls. 206/207).

Esclareceram os policiais militares em exercício que receberam informações de que estaria ocorrendo armazenamento e comercialização de entorpecentes em uma residência na Av. Armando Sales de Oliveira, nº 737, local segundo o qual seria frequentado por jovens e haveria grande quantidade de drogas armazenada. A equipe deslocou-se ao local, inclusive com foto e qualificação do suspeito, ora custodiado. No local foram atendidos pelo custodiado, o qual, certificado quanto à denúncia, franqueou a entrada na residência e confirmou que havia drogas na casa, dando ensejo à apreensão da grande quantidade descrita na denúncia.

Vale lembrar, recente decisão da Suprema Corte Constitucional, acerca do tema, no Recurso Extraordinário nº 1.342.077, relatada pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, quando foi dado parcial provimento ao recurso para anular o v. acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação.

Quando do julgamento sobredito, o eminente Ministro Relator esclareceu que o Egrégio Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, "pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - gravação audiovisual da anuência de entrada no local - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral" (cf.:

<https://www.migalhas.com.br/quentes/356008/moraes-anula-decisao-do-stj-que-obrigou-aparelhamento-de-policiais>).

Ademais, nunca é demais lembrar que se o acusado foi detido em estado de flagrância, mantendo consigo entorpecente, ilicitude penal esta de natureza permanente, não há que se asseverar a ocorrência de prisão ilegal, por falta de mandado de busca e apreensão, já que caracterizada a hipótese excepcionalizada pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (cf. STJ, HC 26.929/RR, 5ª Turma Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 18/08/2003).

No mesmo diapasão:

Quanto à alegação de ilicitude das provas decorrentes do flagrante, como é cediço, havendo flagrante em crime de tráfico ilícito de substância entorpecentes - infração penal de natureza permanente -, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial. Caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecente, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do investigado ou suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno (TJ-BA - HC: 00217898420168050000, Relator: José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 16/02/2017).

No mesmo sentido:

Nulidade - Tráfico de entorpecentes - Agente flagrado com 04 porções de maconha, mantendo em depósito outras 47 porções de cocaína sob a forma de crack - Ausência de prévio mandado judicial de busca e apreensão - Situação de flagrante cuja concretização é hábil para confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões

que justificavam a adoção da medida - Inocorrência [...] O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema n.º 280, observou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial será lícita, mesmo em período noturno, desde que venha "amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". Conclui-se, portanto, que, conquanto seja efetivamente recomendável que aludida entrada forçada em domicílio venha, sempre que possível, precedida de mandado judicial, de tal sorte a respaldar previamente a conduta dos policiais na hipótese de a diligência ser infrutífera, fato é que eventual concretização do flagrante será evidentemente hábil a confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões justificando a adoção da medida pela situação de flagrante delito. Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo 04 porções de maconha e tem em depósito 47 porções de crack - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "trazer consigo" e de "ter em depósito". (TJ-SP - APR: 15013977820208260047 SP 1501397-78.2020.8.26.0047, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/05/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/05/2021).

Rejeito, destarte, a alegação de ausência de autorização.

2.1. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 18), pelos laudos periciais do entorpecente (fls. 27/29 e 96/98), pelos laudos periciais dos objetos apreendidos (fls. 88/89, 90/92, 93/95) e pelo relatório técnico referente ao aparelho celular (fls. 258/679).

Na fase policial o acusado aduziu que possui 22 (vinte e dois) anos. É solteiro.

Não possui filhos. É investidor financeiro (trader). Não possui antecedentes criminais. Quanto aos fatos, exerce o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 12/13).

Em Juízo o réu negou os fatos, tendo aduzido que geralmente, às sextas-feiras, ia até a residência do 'ROBINHO' para realizarem um 'torneio de futebol' no videogame. Na data dos fatos, estavam em cerca de oito amigos. Estavam jogando videogame normalmente quando escutaram o barulho no portão. Três policiais ingressaram na sala. Os castrenses pediram para que todos colocassem as mãos na cabeça e foram colocando todos para fora. Quando já estavam todos na área, os policiais perguntaram 'quem é o LUAN?'. O interrogado informou aos castrenses que a casa não era sua. Não conhece os policiais que procederam à abordagem. Aos poucos, os castrenses foram liberando os colegas. Os policiais, ao 'liberar' os amigos, dizia para cada um deles que não era 'para ligar para ninguém'. Os policiais liberaram até mesmo o dono do imóvel. O acusado, por fim, ficou sozinho com os castrenses. Posteriormente, os policiais foram revistar a residência. Em determinado momento, um dos policiais afirmou que era para o acusado gravar um vídeo, dizendo que autorizava a entrada deles no imóvel. O acusado não possuía drogas consigo. Não tinha conhecimento do vídeo dos castrenses, com o canil, encontrando droga no imóvel. Não possui passagens pela polícia. Na época do ocorrido, estava trabalhando no lava rápido 'Lanchonete Plus', que pertencente ao pai, localizado próximo ao 'Avenida Plus'. A residência onde os fatos ocorreram pertencia a 'ROBINHO'. Não sabe o motivo pelo qual 'ROBINHO' não foi ouvido. Na ocasião, jogavam videogame na sala do imóvel 'da frente'. O interrogado afirma que nunca entrou na 'parte dos fundos' do imóvel. Não sabe o motivo de os policiais terem escolhido o réu entre várias outras pessoas que estavam no local. Os castrenses não bateram palma antes de ingressarem no imóvel, eles já foram 'entrando'. Não acompanhou a busca realizada pelos policiais no interior da casa. Não visualizou os castrenses adentrarem na residência 'dos fundos'. No seu depoimento na Delegacia, não declarou que residia na Av. Armando Salles de Oliveira, nº 737. Informou o endereço da Av. Armando Salles apenas quando lhe perguntaram o local em que haviam ocorrido os fatos. Informou que residia na Rua dos Crisântemos, nº 192, no Parque das Acácias, juntamente com os avós. Teve assistência de 2 (dois) advogados. No momento em que

informou o seu endereço na Delegacia, acredita que os seus advogados não estavam presentes. Pelo que se recorda, os advogados chamavam JOÃO VITOR CAPUTO e JULIANA CRUZ. Estava estudando sobre 'mercado financeiro' e, quando o advogado perguntou com o trabalhava, informou que 'trabalhava com mercado financeiro e que ajudava seu pai no lava rápido'. Conheceu 'ROBINHO' no futebol, e não sabe o nome completo de 'ROBINHO'. Começou a frequentar a residência de 'ROBINHO' do mês de 'maio para frente'. Conhecia o 'ROBINHO' do futebol desde o ano passado. A gravação feita pelos policiais foi realizada após a chegada do canil. O acusado não possui cachorro (fls. 206/207).

O Policial Militar Paulo obtemperou que na data do ocorrido, estava em serviço na modalidade ROCAM. Por volta das 14h00, quando estava em patrulhamento pela Avenida Armando Salles, recebeu uma denúncia, advinda de um comerciante, de que 'algo de errado acontecia naquela residência', e que 'tinha certeza de que estava ocorrendo tráfico de drogas ali'. A denúncia foi precisa. Como conhece a pessoa que denunciou, foi verificar a informação obtida, dirigindo-se até o imóvel O réu estava na casa. O depoente se identificou e informou ao denunciado o que estava acontecendo, e que havia ido até a residência para realizar uma averiguação de tráfico de drogas. O réu ficou nervoso com a presença dos policiais no imóvel e afirmou que havia entorpecentes no local. A princípio, o denunciado não informou o local em que os narcóticos estavam armazenados. O acusado autorizou a entrada dos castrenses no imóvel. Com a ajuda do canil, a droga foi localizada embaixo de uma estante, sendo que, no mesmo local, também havia uma balança. Foram encontrados cerca de 22 (vinte e dois) tabletes de maconha. Em continuação nas buscas, também foi localizado no interior de um guarda-roupa, 1 (uma) porção de 'haxixe' com peso aproximadamente de 100 g (cem gramas). Ao lado da porção de 'haxixe', havia a quantia de R\$ 1.842,00 (mil oitocentos e quarenta e dois reais). No momento da abordagem, o acusado possuía consigo cerca de R\$ 900,00 (novecentos reais), além do aparelho celular. Indagado, o réu afirmou que o entorpecente era de sua propriedade, mas não revelou se comercializava drogas. O denunciado cooperou com as diligências. Posteriormente, o acusado foi apresentado na Delegacia. Soube, por outros policiais, que, em datas anteriores, 'as pessoas reclamavam de barulho e cheiro de entorpecente' no local. Não conhecia o acusado. Nunca abordou o réu anteriormente. No momento em que ingressou no imóvel, o denunciado estava 'próximo à porta'. Estava apenas o acusado na residência. Em Assis, não há o costume de acionar a polícia civil técnica para realizar perícia do local. A residência do réu fica localizada 'nos fundos' do imóvel. O terreno possui duas construções. O denunciado autorizou o ingresso dos castrenses no local, havendo uma gravação. Durante o depoimento, foram mostrados dois vídeos gravados, disponibilizados pela testemunha, sendo que em um deles consta o acusado autorizando o ingresso dos policiais na residência, e no outro, o cão farejador encontrando a droga na estante (fls. 206/207).

O Policial Militar Renato falou que na data dos fatos, estava em patrulhamento na modalidade ROCAM. Quando estava passando pela Av. Armando Salles, recebeu informações de um comerciante do local, mencionando que havia um indivíduo chamado LUAN que estava armazenando e traficando drogas, em uma residência localizada na Av. Armando Salles de Oliveira, nº 737. Soube, ainda, que o local era muito frequentado por jovens e que lá estava havendo o comércio de entorpecentes. O depoente dirigiu-se ao imóvel e, em um primeiro momento, o Cabo Negrini fez contato com o acusado. O réu abriu o portão e foi cientificado da denúncia, bem como que os policiais estavam na casa para realizarem uma averiguação de tráfico de drogas. O denunciado ficou nervoso. O acusado autorizou o ingresso dos castrenses na residência para que fossem realizadas as buscas. O réu informou que residia na casa 'dos fundos', e que na 'casa da frente' não havia ninguém. Com o apoio do canil, foram localizados 22 (vinte e dois) tabletes de maconha, uma balança de precisão, além de uma faca com resquícios da mesma droga, todos acondicionados em uma sacola preta, inseridos embaixo de uma 'estante'. Em continuação com as buscas, foi encontrada no interior de um guarda-roupa, uma pequena porção de maconha e 'haxixe', além de outra balança de precisão. Foi localizado também a quantia de R\$ 1.842,00 (mil oitocentos e quarenta e dois reais) em notas diversas. O réu possuía

consigo o equivalente a R\$ 900,00 (novecentos reais) em notas diversas, além de um aparelho celular. Indagado, o denunciado afirmou que o entorpecente era de sua propriedade, mas não deu mais informações. Posteriormente, o acusado foi conduzido até a Delegacia. As diligências ocorreram no período da tarde. A casa 'da frente' estava fechada. Estava apenas o réu no imóvel. As buscas duraram cerca de uma hora. Não se recorda se havia um aparelho de vídeo game na residência. O denunciado acompanhou as buscas na casa. Não chegou a perguntar ao acusado se o imóvel era de sua propriedade. Não conhecia o réu (fls. 206/207).

A testemunha Fabricio, arrolada pela defesa, asseverou que o acusado é seu amigo de infância. Estava no local dos fatos quando os policiais chegaram, pois havia ido jogar videogame. A residência pertence a 'ROBINHO'. No momento em que os castrenses chegaram, estava na sala 'jogando'. Há 2 (duas) casas no terreno. Estava na sala da residência 'da frente', juntamente com o réu e outros amigos, como o 'ROBINHO, o BRUNO, o PAULINHO', entre outros. Os policiais adentraram na residência e ordenaram que ficassem de cabeça baixa. Após colocarem 'todos' na área, os castrenses perguntaram 'quem era o LUAN?', e levaram o denunciado para um 'canto'. O acusado afirmou aos policiais que não tinha conhecimento sobre nenhuma droga. Na ocasião, os castrenses mencionaram que, caso o depoente 'entrasse em contato com algum familiar, ia causar problema'. Não conhece os policiais que procederam à abordagem. O réu reside no Parque das Acácias. Às vezes, os meninos faziam algumas 'festas' na residência. Os castrenses chegaram 'do nada' no imóvel. Na 'casa da frente' reside apenas 'ROBINHO'. A residência 'dos fundos' estava desocupada. O denunciado ficou sozinho no imóvel com os policiais. Quando foram todos embora, os castrenses ainda não haviam encontrado a droga. Os policiais informaram que estavam em busca de entorpecentes. A testemunha entrou em contato com o pai do acusado e soube que o réu estava preso. Não sabe o motivo pelo qual o réu foi preso sendo que 'nem lá ele residia'. Não possui passagem pela polícia (fls. 206/207).

A testemunha Bruno, arrolada pela defesa, disse que conhece o acusado desde a infância. Estava presente no momento dos fatos. Os policiais chegaram colocando 'todos para fora'. O ocorrido se deu em uma sexta feira por volta das 16h00. Toda sexta feira 'marcavam' de jogar videogame. Eram três policiais. O portão da residência estava fechado, mas não trancado. Os policiais abriram o portão e ingressaram no imóvel, 'já com a arma na mão'. O depoente ficou na área da casa por cerca de quarenta minutos. Após, os castrenses mandaram o depoente embora e ficou apenas o réu na residência. Soube da prisão do denunciado apenas após ter ligado para o genitor do réu. O imóvel pertencia a 'ROBINHO'. Não chegou a visualizar se o 'caminhão' da Polícia Militar esteve no local. Nunca soube do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Não presenciou o réu autorizando o ingresso dos castrenses no imóvel. No mesmo terreno, há duas residências, uma na parte da frente e outra nos fundos. Não presenciou qualquer busca na residência da frente. Pelo que tem conhecimento, não há morador no imóvel 'dos fundos'. Jogavam o videogame Xbox 360' (fls. 206/207).

A testemunha Paulo, arrolada pela defesa, aduziu que estava no local em que ocorreram os fatos, mas não presenciou a prisão do acusado. Estava na residência do 'ROBINHO', pois havia ido jogar um torneio de videogame. Os policiais chegaram e abriram o portão, 'invadindo' o imóvel e ordenando que todos colocassem as mãos na cabeça e que se dirigissem ao corredor. Eram três policiais e foi perguntando 'quem era o LUAN?'. Não sabe o motivo pelo qual o réu foi preso sendo que 'ele nem morava lá'. Soube que o denunciado foi preso através de 'ligações de amigos'. Não sabe informar o motivo pelo qual os policiais determinaram que apenas o acusado permanecesse no local. Apenas 'ROBINHO' residia naquele imóvel. Não presenciou a conversa do réu com os policiais, nem mesmo as buscas realizadas pelos castrenses. Na casa 'dos fundos' não morava ninguém. Os policiais disseram para a testemunha que caso continuasse lá, 'iria arrumar para a cabeça', por isso não procurou ajuda para o denunciado (fls. 206/207).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita, mormente pelo depoimento dos policiais militares. É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser

respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficientes alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o réu realizava o tráfico na residência, o que ensejou a ida dos castrenses até o local em que o acusado foi abordado, a quantidade do entorpecente, a apreensão da balança de precisão, e do dinheiro, o que bem demonstra a finalidade da mercancia.

Ademais, ressalta-se o teor das conversas obtidas em análise ao aparelho celular apreendido na posse do acusado, a indicar que se tratava de negociação de venda de entorpecente (cf. fls. 258/679), consoante bem mencionado pelo d. representante do Ministério Público (fls. 692/693).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Vale lembrar que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar.

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de rigor a prolação do decreto condenatório, não se tratando, portanto, de hipótese de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.3. O acusado é primário (cf. F.A. e Certidões 36/39).

Logo, a despeito da expressiva quantidade dos narcóticos apreendidos, curvo-me ao posicionamento atual das d. Cortes Superiores para deixar de utilizar esse fundamento para elevar a pena-base, evitando-se, assim, o odioso bis in idem, já que o mesmo critério será levado em consideração na terceira fase da dosimetria para obstar a aplicação do redutor.

Não há agravante e eventual atenuante não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

In casu, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da expressiva quantidade

da droga apreendida na posse do acusado, a teor do disposto no art. 42 do mesmo diploma legal, já que a referida benesse surgiu para beneficiar aquele que, pela primeira vez, concorre para o tráfico, porém, de pequena quantidade. Ademais, os diálogos existentes no telefone apreendido, na posse do acusado, descritos no laudo (cf. fls. 258/679) e mencionados pelo d. representante do Ministério Público (fls. 692/693), bem indicar que não se trata de mero traficante eventual, cujo fato é corroborado pelos fatos que levaram os policiais até o referido local descrito na denúncia.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (953 PEDRAS DE CRACK e 101 TABLETES DE MACONHA). REGIME PRISIONAL FECHADO. OBRIGATORIEDADE. CRIME COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 11.464/2007. ORDEM DENEGADA. 1. Para efeitos de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, "[a] conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas." (STF, RHC 94.806/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/04/2010.). 2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram que a grande quantidade de substâncias apreendidas - 953 pedras de crack e 101 tabletes de maconha - evidencia o grau de envolvimento do ora Paciente com o tráfico de drogas, distinguindo-o, portanto, do traficante ocasional... (cf. STJ, 5ª Turma, HC 202527/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 28.06.2011, p. em 01.08.2011).

Por essa diretriz, há de ser aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ex vi legis, se o agente for primário, não possuir antecedentes criminais, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

E, no caso dos autos, malgrado seja o réu primário, em razão da manifesta dedicação à atividade criminosa, não faz jus ao privilégio.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Rejeitada a preliminar arguida, julgo procedente o pedido acusatório para condenar LUAN RIBEIRO AVELINO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2, alínea b, do Código Penal.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade, em razão do tempo da prisão cautelar e do regime do cumprimento da pena ora fixado, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) não se ausentar da comarca, por mais de 8 (oito) dias, sem comunicar o Juízo; b) não mudar de endereço, sem comunicar o Juízo; c) recolhimento domiciliar no período noturno, ou seja, das 22h00 às 6h00 e durante os dias de folga; d) proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, informando-se à Polícia Militar para auxiliar na fiscalização das condições sobreditas.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro, do celular e das balanças apreendidas - em favor da União (fl. 18).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA